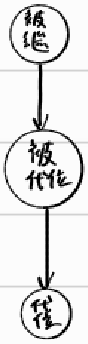
壹、性質

一、代位权说（21院754、胡）：被代位人生前以須有繼承权存在為必要

二、固有权说（SC 32上1992例、87台上1556、通、23院1501）：採前說將有論理上矛盾＋立法意旨

貳、要件



一、繼承开始前被代位人死亡或喪失繼承权（§1140）

1、§1176 ⇒ 拋棄則无法代位

2、繼承後死亡屬再轉繼承，非代位繼承

3、被代位人与繼承人同時死亡

(1) 同時存在原則（§11）⇒ 互不為繼承人

(2) SC 32上1992例、林：代位繼承，係保護代位人之期待利益 ⇒ 仍可代位繼承

4、繼承开始後始生喪失之事由 ⇒ 宜认溯及繼承开始時即生效力（史、胡、模、劉含章）

5、親等較近之直血卑全拋死亡

(1) 本位繼承說：有§1139、1140 ⇒ 以孫子女平均繼承（戴、史、高院93民事8号、彰化地院106家析43、基隆地院106重家析1）

↗ §1140 反面解釋（一人或數人）＋於繼承开始前應繼分本即浮动不定

(2) 代位繼承說：孫輩之應繼分不應變多＋§1138~1140之條文編排順序旨在維護各房之公平，无均分遺產之概念（林、模、振）

6、喪失後所生子女

(1) 肯定說：固有权说，只須視死亡時代位权人是否存在（通、林、戴、振、史）

(2) 否定說：无期待地位（模、劉得寬）

7、喪失後所收養子女

(1) 肯定說：於法无據，且收養已需經法院认可（林、模）（區分說认為仍應具体審查是否以繼承為收養目的（戴））

(2) 否定說：避免失权者以此達成繼承目的（史、劉得寬）

二、被代位人須為被繼承人之直血卑（§1140）

1、无親等限制 ⇒ 孫子女得被代位

2、J70：養子女之婚生子女、養子女之養子女、婚生子女之養子女均得代位

三、代位人須為被代位人直血卑（§1140）⇒ 父母、配偶均不可代位（SC 26渝上608例、41台上546例）

↳ 被代位人子女、孫子女皆存在 ⇒ 類推§1139

四、代位人須為被繼承人之直血卑

1、原因：固有权说

2、收養前養子女已有其直血卑 ⇒ 取決於收養前直血卑与養父母間有无血親关係（ex：§1077Ⅲ）

3、史模、34院解3010
法務部103法律10303508150
认若養子女之子女有意思能力，經同意願留養家例外不消滅 ⇒ 96修正§1083應无法再相同解釋，院解3010應停止適用（林）

↳ 林、模、史：可认留於養家之孫子女得对養祖父母代位繼承 ⇒ §1140應為廣义解釋 ⇒「曾為」直血卑即可

參、效力：代位繼承人有數人應同§1141均分被代位人之應繼分